

1501205-51.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Tal entendimento decorreu do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

1ª Vara Criminal

Avenida 5 nº 545, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501205-51.2019.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501205-51.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência -

2090598/2019 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2460850 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

2305/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2090598 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2305/19/924 -

- DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2090598 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2305/19/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2090598 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2305/19/924 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE CAMARGO DE PAULA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DURVAL JOSE DE MORAES LEME

Vistos.

LUIZ HENRIQUE CAMARGO DE PAULA, qualificado no inquérito, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, assim porque, no dia 20 de março de 2019, por volta das 12h30min, na Avenida 62 A, nº 993, Vila São Miguel, nesta Comarca, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo 10 (dez) microtubos do tipo eppendorf, contendo a substância entorpecente denominada cocaína, e ainda guardava e tinha em depósito outros 15 (quinze) microtubos do tipo eppendorf contendo a mesma substância entorpecente denominada cocaína, totalizando

com aqueles outros peso líquido aproximado de 3,11 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 23/27, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 46/47).

Regularmente notificado (fls. 68), seguiu-se oferecimento de defesa preliminar em favor do Acusado (fls. 72/73), sendo posteriormente recebida a denúncia no dia 11 de junho de 2021 (fls. 74/77).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do Acusado (fls. 99).

Em suas alegações finais, a ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do Acusado, nos termos da denúncia, com fixação da pena base no mínimo legal, possibilitando-se a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional inicial aberto, em caso de reconversão (fls. 99).

A ilustre Defensora Pública, a sua vez, inicialmente sustentou comprometida a materialidade do delito, por derivação, assim porque ilícita a busca pessoal que resultou na apreensão do entorpecente, dada a ausência de prévia e fundada suspeita, em violação ao disposto no artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal, a determinar a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim não se entendendo, pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, dada a diminuta quantidade de entorpecente apreendida com o acusado, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. No mérito, sustentando frágil a prova produzida, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo Estatuto Processual Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito atribuído inicialmente ao acusado para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Em caso de condenação pela imputação inicial, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional inicial aberto, facultando-se, por fim, a interposição de recurso em liberdade (fls. 99).

Em síntese, o RELATÓRIO.

DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, assim porque, com intuito mercantil, para consumo de terceiros, trazia consigo e, ainda, guardava e tinha em depósito o entorpecente indicado na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A materialidade do delito vem comprovada pelo que exposto no laudo de exame químico-toxicológico encartado as fls. 23/24 e relatório de fls. 25/27, com resultado positivo para cocaína.

Sustenta-se que a materialidade do delito estaria comprometida, por derivação, já que decorrente a apreensão de busca pessoal ilícita, inexistindo fundada suspeita a autorizá-la, em afronta ao que disposto no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Entretanto, como se extrai da prova produzida, o Acusado se encontrava parado em local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes e revolveu um monte de pedras existentes na calçada, evadindo-se para o outro lado da rua diante da aproximação da viatura policial, a configurar, portanto, a fundada suspeita autorizadora da busca pessoal, que inclusive resultou na apreensão de várias porções de cocaína.

Deste modo, ficam afastadas a objeções deduzidas, que estariam a macular derivadamente a materialidade do delito.

Controverte-se sobre a posse e a destinação mercantil do entorpecente apreendido. Ouvido em Juízo, o Acusado afirmou que estava seguindo para a moradia da namorada, quando encontrou seu conhecido Lucas, que passava de motocicleta e parou para conversarem. Informou que notaram quando algumas pessoas passaram correndo e também a presença da polícia. Após seu conhecido Lucas ter deixado o local, acabou abordado, negando que o entorpecente apreendido lhe pertencesse, tampouco que tenha

sido localizado qualquer entorpecente na pochete que tinha consigo, admitindo, por fim, que fazia uso de maconha naquela época (fls. 99).

A versão deduzida pelo acusado, contudo, foi contrariada pela prova oral produzida. De fato, o Policial Militar Leandro, que foi ouvido em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento em local conhecido por ser ponto de intenso tráfico de entorpecentes, quando o Acusado foi avistado abaixado, próximo a algumas pedras, junto a um muro, e, com a aproximação da viatura, ele se levantou e saiu do local. Tendo em vista a localidade, aliada ao comportamento suspeito, foi ele abordado e, em busca pessoal, foi apreendido com ele entorpecente. Ademais, naquele local por ele revólvido, foi apreendida outra quantidade de entorpecente, tendo ele admitido que estava realizando o comércio ilícito (fls. 99).

No mesmo sentido a testemunha Emerson, também Policial Militar, esclarecendo que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro São Miguel e avistaram o Acusado mexendo em um monte de pedras, defronte a uma moradia. Diante da aproximação policial, ele se levantou e atravessou a rua, em razão da atitude suspeita sendo realizada a abordagem. Na busca pessoal foram apreendidos, no interior de uma pochete que levava, dez microtubos contendo cocaína. Naquele local, onde foi visto abaixado inicialmente, foram localizadas mais quinze porções contendo a mesma substância ilícita. Informou, por fim, que o Acusado admitiu a comercialização ilícita, mas se negou a dar outras informações (fls. 99).

Não há nenhuma indicação de que os Policiais Militares estivessem animados do propósito de incriminar o Acusado, gozando os depoimentos da presunção de veracidade.

A propósito: "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais que oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (in Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e Outros, 3ª ed., RT, p.1829).

Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Acresça-se que "é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E, ainda: "cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Não é suficiente a mera alegação por simplesmente serem os depoentes policiais" (Apelação nº 990.09.216746-4, TJSP, Rel. Salles Abreu).

Deste modo, do que vem de ser exposto, tem-se por evidenciada não apenas a posse do entorpecente, mas também a sua destinação mercantil.

É que foi o Acusado abordado no momento em que se afastava de local já conhecido pelo intenso comércio ilícito de entorpecentes, onde momentos antes revolvía um monte de pedras, apreendendo-se com ele e neste local várias porções semelhantes de cocaína, além de ter admitido informalmente a realização do tráfico, compondo, portanto, circunstâncias que possibilitam suficiente juízo de convicção sobre a destinação mercantil do entorpecente.

Ademais, não se mostra possível a incidência do princípio da insignificância em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, seja porque não é ínfima a quantidade apreendida com o acusado, distribuída em 25 (vinte e cinco) porções de droga, substância de maior potencial lesivo (cocaína), seja ainda porque se cuida de crime de perigo abstrato, não obstante a tipificação do delito a menor quantidade

entorpecente apreendida.

Sobre isto: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente" (AgRg no HC n.645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.163/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 1501377-90.2019.8.26.0510 - 9 08/10/2021)".

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Considerando o disposto no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42 da Lei de Tóxicos, diante das circunstâncias pessoais favoráveis, possível seja fixada a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de considerar a circunstância atenuante da menoridade, porque já fixada a pena-base no mínimo legal (Súmula 231, STJ).

No entanto, a pena-base cominada deve ser reduzida, em função do que disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. De fato, o Acusado é primário, relativamente menor, não integra organização criminosa e não se reuniram elementos probatórios que evidenciassem estivesse ele dedicado à atividade mercantil ou se se tratava de envolvimento ocasional.

Assim, não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, deve a pena-base ser reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do Acusado.

Diante da operada redução da pena inicialmente cominada, caracterizando a figura do tráfico privilegiado, devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme entendimento que se consagrou no Colendo Supremo Tribunal Federal e Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sobre isto, revendo entendimento consolidado anteriormente, com consequente cancelamento da Súmula nº 512, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que o tráfico de entorpecente, em sua forma privilegiada, não tem natureza hedionda. Segundo o decidido, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no artigo 33 "caput" e §1º, da Lei 11.343/06 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa".

Além disto, destacou-se que, apesar da vedação constitucional e legal da concessão de graça e anistia e de indulto ao tráfico de entorpecentes, "os Decretos Presidenciais nº 6706/08 e 7049/09 beneficiaram os condenados pelo tráfico de entorpecentes privilegiado com o indulto, o que demonstra que os mencionados textos normativos inclinaram-se na corrente doutrinária de que o tráfico privilegiado não é hediondo. Tal entendimento decorreu do posicionamento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão relatado pela Ministra Carmem Lúcia, observando-se que a decisão do legislador fora no sentido de que o agente deveria receber tratamento distinto daqueles sobre os quais recairia o alto juízo de censura e de punição pelo tráfico de drogas e de que as circunstâncias legais do privilégio demonstrariam o menor juízo de reprovação e, em consequência de punição (HC 118.533/MS, 23/06/2016).

Acrescentou-se que nem toda transação ilícita com drogas deve necessariamente submeter-se ao regime dos crimes hediondos, como a conduta de quem oferece droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem (art. 33, §3º, Lei 11.343/06), bem como a de quem, de forma episódica, pratica o denominado tráfico privilegiado (art. 33 §4º, Lei 11.343/06).

Nesta linha de raciocínio, consignou-se que o artigo 44 da Lei de Tóxicos, ao estabelecer que os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 a 37 da Lei 11.343/06 "são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", conferiu ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º), tratamento especial ao que o legislador atribuiu ao caput e ao §1º do artigo 33, a reforçar a tese de que não se trata de delito hediondo.

Ainda segundo o que decidido, o conceito de hediondez é de todo incompatível ao de privilégio, conforme há muito vem decidindo o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que diz com o homicídio qualificado-privilegiado, não se lhe aplicando o disposto na Lei 8072/90, afastando, portanto, a natureza hedionda.

Concluiu-se que o julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ainda que por seu Órgão Pleno, não tem efeito vinculante nem eficácia erga omnes.

No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, nos termos do artigo 927, §4º, do Código de Processo Civil, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito daquele Egrégio Tribunal Superior, entendeu-se ser necessária a revisão da questão, com a determinação da revisão do entendimento anterior, estabelecendo-se a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo.

Desta forma, pelos princípios acima indicados, ressaltando o posicionamento contrário deste julgador, a fim de evitar decisões contraditórias, que mais se potencializam em sede de jurisdição que alcança território mais reduzido, evidenciando desigualdade bastante gravosa, cumpre a este juízo também se alinhar à jurisprudência do Pretório Excelso.

Assim, cumpre seja a pena privativa substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena cominada, a ser dirimida em execução, como também por uma pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamentos no artigo 33, "caput", c.c. §4º, da Lei nº 11.343/06, CONDENO o acusado LUIZ HENRIQUE CAMARGO DE PAULA à pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, a ser dirimida em execução, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, corrigido desde a época do fato, além da pena pecuniária equivalente a 1 (um) salário mínimo.

Em caso de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, esta deverá ser cumprida em regime prisional inicial aberto.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Rio Claro, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA